

**El déficit de estándares de valoración probatoria en la justicia electoral
mexicana:
protocolo de adminiculación indiciaria y umbral de suficiencia verificables**

Tesis de Maestría
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales · División de Estudios de Posgrado

Índice

Capítulo 1. Categorías de epistemología jurídica para la prueba por indicios.....	1
1.1. La decisión sobre los hechos es una operación de conocimiento sujeta a control racional.....	1
1.1.1. La racionalidad probatoria es una conquista histórica y no un rasgo definitorio de la función judicial.....	2
1.1.2. Una epistemología moderadamente realista evita tanto la infalibilidad como el escepticismo.....	3
1.1.3. El modelo cognoscitivista exige enunciados fácticos verdaderos y controlables	5
1.1.4. La epistemología jurídica opera en dos proyectos: describir las reglas y reformarlas.....	7
1.2. La averiguación de la verdad es la función epistémica del proceso.....	8
1.2.1. Sin averiguación de la verdad el derecho fracasa como mecanismo de dirección de conducta.....	9
1.2.2. La verdad de los hechos es condición necesaria, aunque no suficiente, de la justicia de la decisión.....	10
1.2.3. Las concepciones ritual y retórica de la prueba renuncian a la función epistémica.....	11
1.2.4. La verdad procesal es relativa a la cantidad y la calidad de las pruebas.....	12
1.3. La actividad probatoria se descompone en tres momentos.....	14
1.3.1. La conformación del conjunto de elementos de juicio concentra las restricciones jurídicas.....	14
1.3.2. La valoración es el momento de la racionalidad y su resultado es contextual	16
1.3.3. Sin estándar de prueba la valoración no determina decisión alguna.....	17
1.3.4. La distinción de los tres momentos ordena el protocolo y el umbral.....	18

Capítulo 1

Categorías de epistemología jurídica para la prueba por indicios

SUMARIO: 1.1. *La decisión sobre los hechos es una operación de conocimiento sujeta a control racional.* 1.2. *La averiguación de la verdad es la función epistémica del proceso.* 1.3. *La actividad probatoria se descompone en tres momentos.* 1.4. *La inferencia probatoria tiene una estructura identificable.* 1.5. *La solidez de la inferencia admite criterios de control.* 1.6. *El conjunto probatorio excede la suma de sus elementos.* 1.7. *La libre convicción no es un criterio de valoración.* 1.8. *Un estándar subjetivo no cumple la función de un estándar.* 1.9. *La motivación convierte la decisión en objeto de control externo.* 1.10. *Recapitulación.*

1.1. La decisión sobre los hechos es una operación de conocimiento sujeta a control racional

La valoración de la prueba admite control racional o queda entregada a la conciencia del juzgador, y entre esas dos posibilidades no existe término medio. La elección condiciona todo lo que este trabajo propone, porque un protocolo de administración y un umbral de suficiencia solo tienen sentido bajo la primera. Ambos instrumentos presuponen que la fijación judicial de los hechos constituye una operación de conocimiento, susceptible de acierto y de error. Este apartado sostiene que lo es y fija las categorías de la epistemología jurídica que permiten demostrarlo. Tres razones sustentan la conclusión: la racionalidad probatoria fue una conquista histórica y no un rasgo definitorio de la función judicial. El conocimiento de hechos admite, además, un realismo moderado que evita por igual la infalibilidad del juzgador y el escepticismo sobre la prueba. Ese realismo se traduce, por último, en un modelo que exige enunciados verdaderos y controlables desde fuera de la sentencia.

1.1.1. La racionalidad probatoria es una conquista histórica y no un rasgo definitorio de la función judicial

La tradición jurídica trató durante siglos el conocimiento de los hechos como una cuestión pacífica. Gascón Abellán (2010) resume el lema de esa tradición con una fórmula exacta: «Los hechos son los hechos y no necesitan ser argumentados» (p. 11). La confianza descansaba en la evidencia de los hechos, y lo evidente no reclama justificación alguna. La autora advierte, sin embargo, que esa seguridad nunca estuvo presente en todos los modelos judiciales. Sostiene también que la historia del empirismo es la crónica de los intentos y fracasos por encontrar un lugar para el conocimiento empírico dentro de la racionalidad (Gascón Abellán, 2010, p. 11). La premisa tradicional resulta falsa como descripción histórica, y su falsedad no constituye una curiosidad erudita. De ese examen depende el estatuto de toda la propuesta que sigue, porque una racionalidad conquistada es una racionalidad que puede perderse.

Durante un largo periodo la construcción de la premisa fáctica se apoyó en ritos y procedimientos mágicos donde no cabía apelación alguna a la razón. Gascón Abellán (2010) describe esa etapa como una experiencia mística de búsqueda de la verdad. Añade que a veces se trató, más simplemente, de la búsqueda de una decisión aleatoria o de un dictamen sobrenatural, antes que de un método con apariencias de racionalidad (p. 12). El caso característico es la ordalía, entendida en sentido amplio como duelo judicial, ordalía y juicio de Dios (Gascón Abellán, 2010, p. 12). Caminar sobre brasas incandescentes sin sufrir lesión resolvía la imputación, y recoger un anillo sumergido en agua hirviendo producía idéntico efecto. Esas prácticas no averiguaban hechos: los sustituían por un veredicto de origen sobrenatural. El vencimiento en duelo demuestra la fuerza, la destreza o la suerte del reo, pero nada acerca de los hechos imputados. Gascón Abellán (2010) concluye que el proceso se convierte entonces en un medio que constituye la verdad, en lugar de un medio que intenta averiguarla (p. 13). La diferencia entre constituir y averiguar recorre todo este trabajo.

El tránsito hacia la prueba legal tasada mejoró la apariencia de racionalidad sin alterar la estructura del problema. Gascón Abellán (2010) explica que la prueba de ordalía y la prueba legal constituyen supuestos de prueba formal, porque ambas excluyen la libre valoración del juez (p. 14). Una y otra la sustituyen por un juicio infalible y superior, y la diferencia entre un juicio divino y un juicio legal no rompe esa continuidad. La fijación de los hechos en todo sistema tasado adopta, además, un

carácter encubiertamente deductivo. Si la confesión prueba de manera incontrovertible la culpabilidad y el reo confesó, entonces el reo resulta culpable por necesidad lógica. Ese procedimiento no aspiraba a una verdad probable, sino real (Gascón Abellán, 2010, p. 15). El ritual probatorio valía por sí mismo, con independencia de los hechos que decía acreditar.

De esa reconstrucción se sigue una consecuencia que interesa de manera directa a esta investigación. La comprensión de la actividad judicial como operación racional constituye una cualidad asociada a determinada cultura jurídica, y no un rasgo conceptual o definitorio de aquélla (Gascón Abellán, 2010, p. 13). La racionalidad probatoria no viene dada con la función de juzgar: se conquistó a lo largo de siglos y, por lo mismo, puede perderse sin que ninguna norma se derogue. El capítulo segundo documenta un episodio de esa naturaleza en la justicia electoral mexicana. Una práctica valorativa construida durante casi tres décadas dejó de aplicarse allí sin que ningún criterio fuera abandonado de manera expresa. La contingencia histórica de la racionalidad probatoria es, por tanto, el supuesto que vuelve necesaria una propuesta como la presente.

1.1.2. Una epistemología moderadamente realista evita tanto la infalibilidad como el escepticismo

La distinción entre verdad y prueba organiza el problema epistemológico del proceso. La primera designa la correcta descripción de un mundo independiente, y la segunda, la descripción de ese mundo formulada en el proceso (Gascón Abellán, 2010, p. 40). Dos tradiciones cancelaron esa dualidad por caminos opuestos. La ciencia procesal continental las identificó desde una epistemología realista acrítica, según la cual los procedimientos probatorios arrojan resultados infalibles. La tradición del *common law* las canceló desde el extremo contrario, al sostener que no hay más verdad que la procesalmente declarada. Gascón Abellán (2010) señala que ambas desembocan en el mismo corolario inquietante: los jueces serían, por definición, infalibles (p. 40). Ese corolario resulta inadmisibile para cualquier teoría que aspire a controlar la decisión sobre los hechos, porque un juez infalible es un juez incontrolable.

Gascón Abellán formula la objeción con una precisión difícil de mejorar. La distinción entre esos dos conceptos, escribe, es posible e incluso necesaria si se quiere dar cuenta del carácter autorizado, pero falible, de la declaración de hechos de la sentencia (Gascón Abellán, 2010, p. 41). Que la decisión ponga fin a la

controversia no convierte en verdadero el enunciado que la sostiene. Mantener la distinción obliga a reconocer que la sentencia puede equivocarse. Cancelarla convierte el error judicial en una categoría conceptualmente imposible. La consecuencia práctica de esa cancelación es considerable. Un sistema que no puede pensar su propio error tampoco puede diseñar garantías contra él. Menos aún puede admitir que una parte demuestre haberlo padecido, que es precisamente lo que un recurso pretende. La falibilidad de la sentencia no es una concesión al escepticismo: es la condición de que exista algo que revisar.

La salida no consiste en elegir entre realismo ingenuo y escepticismo. Gascón Abellán (2010) sostiene que ese dilema es infundado y que existe, como poco, una tercera vía (p. 42). Esa vía adopta un paradigma epistemológico que toma en serio las tesis postpositivistas sobre la carga teórica de la observación, sin renunciar por ello a un cierto realismo. El juicio de hecho pasa entonces a concebirse como una elección entre reconstrucciones posibles de los hechos de la causa. Taruffo (2013) precisa el criterio de esa elección al exponer la regla de la probabilidad prevalente. Resulta racional escoger, respecto de un enunciado de hecho, la hipótesis confirmada en un nivel mayor al de la hipótesis contraria (p. 61). Cuando concurren varias hipótesis sobre el mismo hecho, el criterio racional consiste en elegir la que aparece sustentada por un grado de corroboración probatoria relativamente mayor al de todas las demás (Taruffo, 2013, p. 62). La fórmula anticipa con exactitud el estándar escalonado que se propone en el capítulo cuarto de este trabajo.

El realismo moderado tiene un rendimiento metodológico que conviene subrayar. La distinción entre verdad y prueba pone de manifiesto la necesidad de establecer garantías epistemológicas para que la declaración de hechos se aproxime lo más posible a la verdad (Gascón Abellán, 2010, p. 41). El protocolo de administración que se propone en el capítulo tercero pertenece íntegramente a esa categoría. No promete verdad, sino que reduce la probabilidad de error y hace visible el recorrido por el que se llegó a la conclusión. La simetría del argumento merece atención. Un tribunal que se declara infalible no necesita garantías epistemológicas, porque por hipótesis nunca yerra, y un tribunal que niega la posibilidad de conocer tampoco las necesita, porque no hay nada que garantizar. Solo el realismo moderado las vuelve exigibles, y por eso constituye el presupuesto de toda la propuesta.

1.1.3. El modelo cognoscitivista exige enunciados fácticos verdaderos y controlables

El realismo moderado se concreta en un modelo determinado de conocimiento judicial de hechos. Gascón Abellán (2010) lo formula en los siguientes términos:

El modelo epistemológico que vamos a adoptar es el cognoscitivista. Entendemos por tal aquel modelo según el cual los procedimientos de fijación de los hechos se dirigen a la formulación de enunciados fácticos que serán verdaderos si los hechos que describen han sucedido y falsos en caso contrario. (p. 49)

El concepto de verdad que el modelo requiere es el semántico de la correspondencia, y su principal criterio de verdad es la contrastación empírica (Gascón Abellán, 2010, p. 49). La fijación de los hechos no puede resultar, por tanto, del puro decisionismo ni del constructivismo. Debe ser el resultado de un juicio descriptivo sobre hechos a los que se atribuye existencia independiente del proceso. El modelo excluye así, desde el principio, la idea de que la verdad se construya en el tribunal. Esa exclusión tiene un precio y una ventaja. El precio consiste en admitir que la sentencia puede errar. La ventaja consiste en que ese error se vuelve alegable por las partes y revisable por el órgano superior, lo que sería imposible si la verdad se agotara en lo declarado.

Los dos adjetivos del modelo cargan con exigencias distintas. Que los enunciados sean fácticos significa que describen hechos acaecidos, de donde deriva una exigencia para el derecho sustantivo: la configuración legislativa del supuesto de hecho debe tener un referente empírico claro (Gascón Abellán, 2010, p. 49). Que los enunciados sean verdaderos plantea el problema principal, y la autora identifica tres razones por las cuales afirmarlo no es una cuestión trivial. El juez carece de acceso directo a los hechos y solo conoce enunciados sobre ellos, cuya verdad debe acreditarse. La verdad de tales enunciados se obtiene casi siempre por vía inductiva, a partir de otros enunciados fácticos. La averiguación se desarrolla, por último, a través de cauces institucionales que muchas veces estorban ese objetivo (Gascón Abellán, 2010, pp. 49-50). Las tres dificultades se acumulan en la prueba por indicios, que es la que ocupa a este trabajo.

De esas tres dificultades deriva la exigencia que atraviesa el presente trabajo, pues reforzar al máximo las garantías de verdad del proceso supone, al final, una exigencia de motivación (Gascón Abellán, 2010, p. 50). La primera dificultad resulta especialmente pertinente para la prueba indiciaria en materia electoral. El juzgador no presencié la entrega de propaganda ni la intervención de servidores públicos en

la jornada. Lo que tiene ante sí son enunciados sobre esos hechos, contenidos en documentos, imágenes y notas informativas de fiabilidad desigual. Acreditar la verdad de cada uno de esos enunciados, antes de relacionarlos entre sí, constituye el segundo paso del protocolo que se propone más adelante. La omisión de ese paso explica buena parte de los defectos que documenta el capítulo segundo. Un tribunal que no fija el hecho fuente carece de material sobre el cual razonar.

El modelo cumple dos funciones que conviene distinguir con cuidado. Como esquema teórico permite describir de manera simplificada realidades que en la práctica son complejas, y como parámetro permite medir esas mismas realidades desde el propio modelo (Gascón Abellán, 2010, p. 47). Gascón Abellán (2010) precisa que lo buscado es un modelo epistemológico teórico y útil (p. 48). Su utilidad consiste en examinar los procedimientos reales y en realizar una crítica epistémica sobre ellos. Esa crítica compara tales procedimientos con los principios derivados del modelo y propone la reforma de los aspectos que se separen de él. Esta investigación adopta la doble función sin alteraciones. El capítulo segundo describe una práctica jurisdiccional, y los capítulos tercero y cuarto la miden contra un modelo y formulan la propuesta correspondiente. Describir y proponer son operaciones distintas, y el trabajo las mantiene separadas para que la crítica no se confunda con el diagnóstico.

La autora acompaña el modelo de una advertencia que este trabajo asume como límite propio. Un modelo de descubrimiento no puede confundirse con el descubrimiento mismo, ni un modelo de justificación con la justificación. Confundirlos supone incurrir en la falacia normativista de quien toma el deber ser por el ser (Gascón Abellán, 2010, pp. 48-49). El riesgo consiste en presentar la práctica real «como si» transcurriera conforme al modelo, y un protocolo de valoración corre exactamente ese peligro. Puede degradarse hasta convertirse en una plantilla que legitime formalmente decisiones que no ejecutaron ninguno de sus pasos. El capítulo tercero atiende la objeción mediante una exigencia precisa: cada paso debe constar de manera verificable en el texto de la sentencia, y no basta con invocarlo en abstracto. La diferencia entre ejecutar un método y nombrarlo resulta central para el diagnóstico de este trabajo.

1.1.4. *La epistemología jurídica opera en dos proyectos: describir las reglas y reformarlas*

La disciplina que estudia estas cuestiones recibió un nombre y un programa precisos. Laudan (2013) sostiene que un sistema de justicia penal es primordialmente un motor epistémico (p. 23). Lo define como un dispositivo para descubrir la verdad a partir de lo que a menudo comienza con una mezcla confusa de pistas e indicios. El autor circunscribe la afirmación al proceso penal, pero la descripción conviene igualmente a la situación del juzgador electoral que examina un conjunto de pruebas imperfectas, ninguna de ellas concluyente por sí sola. Si el proceso es un motor epistémico, resulta pertinente preguntar si los procedimientos y reglas que lo estructuran conducen genuinamente a la averiguación de la verdad (Laudan, 2013, p. 23). Esa pregunta define la disciplina y ordena su programa de trabajo, que el autor delimita en dos proyectos:

De modo que la epistemología jurídica, concebida apropiadamente, consta de dos proyectos: a) uno de carácter descriptivo, consistente en determinar cuáles de las reglas vigentes promueven o facilitan la verdad y cuáles la obstaculizan, y b) otro normativo, consistente en proponer cambios en las reglas existentes al efecto de modificar o eliminar aquellas que constituyan impedimentos graves para la búsqueda de la verdad. (Laudan, 2013, p. 23)

Laudan (2013) advierte que la epistemología jurídica apenas existe como área reconocida de reflexión, pese a la aceptación casi universal de que el proceso busca averiguar la verdad (p. 23). El diagnóstico conserva vigencia en el derecho electoral mexicano, donde la discusión sobre la prueba se ha concentrado en la admisibilidad de los medios y en su valor tasado. La pregunta por la aptitud de las reglas para producir decisiones verdaderas ha recibido, en cambio, atención escasa. Este trabajo se sitúa precisamente en ese espacio vacante. No discute qué pruebas pueden ofrecerse ni cómo deben desahogarse, sino qué debe hacer el juzgador con las que ya obran en el expediente. El desplazamiento del objeto es deliberado, porque el problema diagnosticado no está en la entrada del material probatorio sino en su tratamiento posterior. La diferencia de objeto explica por qué la propuesta no requiere modificar el catálogo legal de medios probatorios, que permanece intacto en cuanto se refiere a su ofrecimiento y desahogo.

La estructura de esta tesis reproduce los dos proyectos con una diferencia relevante. El capítulo segundo desarrolla el proyecto descriptivo, al determinar cómo operó y cómo dejó de operar una regla vigente de valoración relacional. Los

capítulos tercero y cuarto desarrollan el proyecto normativo, aunque no de la manera que Laudan describe. La diferencia consiste en que aquí no se proponen cambios en las reglas existentes. Se propone explicitar el contenido de reglas que ya rigen, porque el diagnóstico no identifica una regla defectuosa sino una regla nunca desarrollada. La propuesta resulta por ello menos ambiciosa que la del autor citado, y gana a cambio una ventaja decisiva. Puede exigirse de inmediato, sin esperar a que ningún órgano legislativo la incorpore al derecho positivo ni a que se abra un ciclo de reforma.

Una precisión final delimita el alcance de este apartado. Gascón Abellán y Laudan construyen sus modelos con la mirada puesta en el proceso penal, y Laudan (2013) organiza el suyo alrededor de la distribución del error entre condenas falsas y absoluciones falsas (p. 22). Este trabajo no traslada ese régimen de garantías a la materia electoral, donde no rige la presunción de inocencia ni existe una asimetría equivalente entre los tipos de error. Toma de ambos autores algo distinto y más básico. Toma la tesis de que la fijación judicial de los hechos constituye una operación de conocimiento y admite, por tanto, criterios de corrección verificables. Esa tesis no depende de la materia en que se aplique. La justificación específica del traslado de categorías se desarrolla en el apartado 3.0.3, cuando el protocolo deba apoyarse en precedentes penales de la Suprema Corte.

1.2. La averiguación de la verdad es la función epistémica del proceso

El apartado anterior estableció que la fijación judicial de los hechos constituye una operación de conocimiento. Queda por determinar qué lugar ocupa ese conocimiento dentro del proceso, y la respuesta no es obvia. Buena parte de la teoría procesal contemporánea niega que la averiguación de la verdad sea una finalidad del proceso, o la subordina a la resolución del conflicto y a la legitimación social de la decisión. Este apartado sostiene la tesis contraria y precisa su alcance. La averiguación de la verdad no es un ideal externo que el proceso persigue cuando puede, sino la condición que permite al derecho funcionar. De esa tesis se siguen dos consecuencias que gobiernan el resto del trabajo. La prueba es el único instrumento epistémico admisible dentro del proceso. Y la verdad alcanzable resulta relativa a la cantidad y la calidad de las pruebas disponibles, lo que la vuelve graduable y, por tanto, mensurable.

1.2.1. Sin averiguación de la verdad el derecho fracasa como mecanismo de dirección de conducta

Ferrer Beltrán (2007) aborda el problema desde las condiciones de éxito de la institución probatoria. Sostiene que para determinar los objetivos de una institución conviene establecer primero cuáles son esas condiciones (p. 29). El punto de partida es la función directiva del derecho. El legislador dicta normas para que sus destinatarios realicen o se abstengan de realizar determinadas conductas, y añade la amenaza de una sanción para quien no cumpla. Los sistemas jurídicos desarrollados prevén, por eso, órganos cuya función principal consiste en determinar la ocurrencia de los hechos a los que el derecho vincula consecuencias y en imponerlas a los sujetos previstos (Ferrer Beltrán, 2007, p. 29). La cadena completa depende de un eslabón fáctico. Si ese eslabón falla, fallan todos los que penden de él, por impecable que sea la técnica jurídica del resto de la resolución.

El autor prueba la tesis mediante un experimento mental. Supone que la sanción se atribuya aleatoriamente, de modo que los órganos de adjudicación sorteen cada mes quién debe ser sancionado y cuántas sanciones se impondrán (Ferrer Beltrán, 2007, p. 30). En ese escenario no existe vinculación alguna entre la conducta de cada miembro de la sociedad y la probabilidad de ser sancionado. Nadie tiene entonces razón para comportarse conforme a las normas jurídicas. El experimento aísla con nitidez lo que aporta la averiguación de la verdad: sin ella, la norma deja de motivar, porque su consecuencia se desprende de algo distinto de la conducta que la norma describe. La conclusión de Ferrer Beltrán (2007) es que la prueba tiene la función de comprobar la producción de los hechos condicionantes a los que el derecho vincula consecuencias jurídicas (p. 30). El éxito de la institución probatoria se produce, en consecuencia, cuando las proposiciones sobre los hechos que se declaran probadas son verdaderas (Ferrer Beltrán, 2007, pp. 30-31).

La tesis admite un matiz que conviene incorporar desde ahora. Que la averiguación de la verdad sea el objetivo institucional de la prueba no significa que sea el único objetivo del proceso. Ferrer Beltrán (2007) advierte que afirmar la finalidad de una institución no excluye la existencia de otras finalidades o propósitos (p. 31). La regulación jurídica de la prueba impone, en muchos casos, excepciones a las reglas de la epistemología general. Esas excepciones protegen otros valores que comparten tutela jurídica con la averiguación de la verdad (Ferrer Beltrán, 2007, p. 31). El derecho electoral ofrece ejemplos inmediatos, empezando por los plazos perentorios que la definitividad de las etapas impone. La existencia de esas

excepciones no debilita la tesis: la refuerza, porque solo se concibe como excepción aquello que se aparta de una regla vigente.

1.2.2. La verdad de los hechos es condición necesaria, aunque no suficiente, de la justicia de la decisión

Taruffo (2013) formula la tesis en términos que no admiten equívoco. Sostiene que en el proceso los hechos determinan la interpretación y la aplicación del derecho, porque la averiguación de la verdad de los hechos es condición necesaria para la justicia de la decisión (p. 13). El argumento es sencillo y difícil de refutar. Ninguna decisión puede considerarse justa si se basa en una averiguación falsa o errónea de los hechos relevantes. La aplicación correcta de la norma presupone que haya ocurrido el hecho que ella misma identifica como condición (Taruffo, 2013, p. 13). El autor lo resume en una fórmula memorable: ninguna norma se aplica correctamente a hechos falsos o equivocados. La corrección jurídica de la sentencia depende, así, de la corrección de su base fáctica.

La afirmación admite una lectura desmedida que conviene descartar de entrada, y el propio Taruffo introduce la precisión. La averiguación de la verdad constituye solo una de las condiciones de justicia de la decisión, que además presupone un proceso desarrollado de manera correcta y legítima y una norma interpretada correctamente (Taruffo, 2013, p. 14). Se trata de una condición de por sí no suficiente, pero necesaria en todo caso. Que los hechos no se establezcan de manera verdadera basta para que la decisión sea injusta, aunque el proceso se haya desarrollado con toda corrección y la norma se haya interpretado con validez (Taruffo, 2013, p. 14). Ninguna de las tres condiciones es suficiente por separado, y las tres resultan necesarias en su conjunto. La distinción entre condición necesaria y condición suficiente sostiene todo el argumento. Quien la pasa por alto puede concluir, erróneamente, que basta con tramitar bien el proceso para decidir con justicia.

El autor identifica y descarta las principales objeciones a esa concepción. Menciona las filosofías que niegan la posibilidad de conocer la realidad externa al sujeto, entre ellas el relativismo radical según el cual cada quien tiene su verdad y nadie se equivoca (Taruffo, 2013, p. 14). Menciona también las concepciones que orientan el proceso solo a resolver controversias, de las que se sigue que la averiguación de la verdad no figura entre sus finalidades (Taruffo, 2013, p. 15). A los sostenedores de esas posiciones los denomina *veriphobics*, o enemigos de la

verdad, y observa que son muchos y de clases distintas (Taruffo, 2013, p. 15). Su crítica global es que, si a esas concepciones no les interesa el fundamento factual de la decisión judicial, entonces carecen de interés para quien se ocupa de cómo resolver litigios mediante decisiones justas (Taruffo, 2013, p. 16).

1.2.3. Las concepciones ritual y retórica de la prueba renuncian a la función epistémica

Dos concepciones merecen examen detenido, porque no niegan la verdad de manera frontal sino que la vuelven irrelevante. La primera es la concepción ritualista, que considera el proceso como un rito celebrado con ciertas modalidades, en lugares específicos y con sujetos vestidos de maneras extrañas (Taruffo, 2013, p. 81). Bajo esa mirada, el proceso opera como una representación teatral cuya función consiste en legitimar la decisión ante los ojos del público que presencia el rito. Lo que cuenta no es la calidad ni el contenido de la decisión, sino el procedimiento que concluye con ella. La prueba queda reducida a una parte del rito, y su función se vuelve retóricamente persuasiva hacia el público (Taruffo, 2013, p. 82). Sirve para hacer creer que la decisión final no fue arbitraria, no para establecer que no lo fue.

Taruffo (2013) extrae la consecuencia sin suavizarla. El procedimiento de creación y asunción de la prueba sirve, bajo esa concepción, para crear una apariencia, de un modo no distinto de lo que sucede en una representación teatral (p. 82). El fenómeno admite una lectura benévola, porque un teatro judicial que funciona bien produce consenso social sobre la administración de justicia. La objeción es que esa forma de pensar deja fuera el contenido y la calidad de la decisión. El autor lo enuncia con dureza: un rito eficaz puede legitimar cualquier decisión, incluso la condena de un inocente o la absolución de un culpable (Taruffo, 2013, p. 82). Basta con que el rito resulte eficaz para que la decisión sea aceptada. La aceptación social sustituye entonces a la corrección, y ninguna de las dos garantiza la otra.

La segunda concepción entiende el proceso como una competencia verbal entre narraciones que termina con la victoria del narrador más eficaz. La prueba se convierte allí en un instrumento de persuasión del que los abogados se sirven para convencer al juez o al jurado (Taruffo, 2013, pp. 82-83). Esta concepción tampoco es extraña ni marginal, pues resulta típica de quienes participan en el proceso con el fin de que su cliente venza. Taruffo (2013) objeta que también ella deja de lado el

contenido y la calidad de la decisión (p. 83). Ocurre con frecuencia que la victoria corresponde a la parte que desarrolló la mejor narración por ser retóricamente más eficaz, sin que esa narración tenga relación con la realidad de los hechos. La función de la prueba se vuelve entonces puramente retórica.

Estas dos concepciones interesan a la presente investigación por una razón que conviene adelantar. Ninguna de ellas exige que el juzgador valore el material probatorio, porque en ambas el resultado depende de algo distinto del conocimiento de los hechos. Una sentencia puede, por tanto, cumplir todas las formas del rito — admitir pruebas, celebrar la sesión, publicar la resolución— sin haber ejecutado en ningún momento la operación epistémica que la justifica. El capítulo segundo documenta una resolución con esas características, en la que el verbo valorar no aparece una sola vez. La distinción de Taruffo permite nombrar con precisión ese fenómeno. No se trata de una valoración defectuosa, sino de un proceso que operó como rito sin operar como instrumento de conocimiento. La diferencia importa, porque una valoración defectuosa se corrige mejorando el razonamiento y una valoración omitida no se corrige en absoluto.

1.2.4. La verdad procesal es relativa a la cantidad y la calidad de las pruebas

Frente a las concepciones anteriores, Taruffo sitúa la finalidad epistémica en el centro del proceso:

De esta forma se asigna al proceso una finalidad epistémica, ya que el descubrimiento de la verdad de las narraciones factuales se configura como una condición necesaria de la justicia de la decisión, y entonces también como un objetivo necesario del proceso. (Taruffo, 2013, p. 84)

La verdad así entendida no es absoluta. Taruffo (2013) precisa que en el proceso, como en cualquier experiencia humana incluida la ciencia, no se descubren verdades absolutas, de modo que la verdad procesal debe considerarse relativa (p. 84).

La relatividad requiere una lectura cuidadosa, y el autor la ofrece. No se trata de verdad relativa en el sentido del relativismo filosófico radical, según el cual cada sujeto tiene su propia verdad. Se trata de que la verdad se fundamenta en informaciones que permiten establecer si un enunciado es cierto, porque se apoya en datos que lo confirman (Taruffo, 2013, p. 84). La formulación decisiva llega enseguida: la verdad de los enunciados sobre los hechos del caso es relativa a la cantidad y la calidad de las pruebas en las que el juez basa su decisión (Taruffo,

2013, p. 84). La verdad opera entonces como un norte, esto es, como un ideal regulativo que orienta la actividad cognoscitiva (Taruffo, 2013, p. 85). Aunque ese norte nunca se alcance, resulta posible establecer cuánto se ha progresado en la dirección que marca.

Esa última idea suministra el fundamento conceptual del capítulo cuarto. Si la verdad procesal es relativa a la cantidad y la calidad de las pruebas, entonces el grado alcanzado es susceptible de medición y, por tanto, de enunciación. En el proceso puede establecerse, según las pruebas, en qué grado mayor o menor se ha acercado la decisión a la correspondencia entre los enunciados descriptivos y la realidad que describen (Taruffo, 2013, p. 85). Un estándar de suficiencia probatoria no hace otra cosa que fijar de antemano el grado exigible. La ausencia de estándar no elimina esa graduación, sino que la deja implícita y, con ello, sustraída al control de las partes. El problema que este trabajo aborda no consiste en que los tribunales gradúen, sino en que no digan cómo lo hacen.

La función epistémica de la prueba se articula, además, en dos dimensiones complementarias. La primera es heurística: la prueba sirve para descubrir qué ocurrió, pues antes de su adquisición solo caben ilaciones y narraciones hipotéticas (Taruffo, 2013, p. 85). La segunda es cognoscitiva o demostrativa, porque la prueba aporta los elementos que permiten reconocer el hecho y considerar verificada la verdad de los enunciados que lo describen (Taruffo, 2013, p. 86). De ambas dimensiones deriva una consecuencia que el capítulo tercero convierte en regla operativa. La prueba constituye un instrumento epistémico exclusivo, por ser la única manera posible de adquirir conocimiento de los hechos en el proceso. Resulta además indispensable adquirir todas las pruebas disponibles (Taruffo, 2013, p. 86). Un tribunal que ignora un elemento que consta en el expediente incumple esa exigencia.

El autor cierra el razonamiento con una precisión sobre el déficit probatorio. Cuando un hecho no resulta suficientemente probado, el juez no puede pronunciar un *non liquet* y debe decidir de todos modos. Habrá de hacerlo, entonces, aplicando la regla de juicio basada en la carga de la prueba, en lugar del conocimiento de los hechos (Taruffo, 2013, p. 86). La observación importa para el diagnóstico de este trabajo. Un tribunal que estima insuficiente el material probatorio dispone de una salida legítima y nombrable, que consiste en declararlo y resolver conforme a la carga de la prueba. Lo que no resulta admisible es omitir la valoración y, al mismo tiempo, omitir la invocación de esa regla de juicio. El capítulo segundo muestra que esa doble omisión es precisamente lo ocurrido en el caso de referencia.

1.3. La actividad probatoria se descompone en tres momentos

Las dos secciones anteriores establecieron que la fijación de los hechos es una operación de conocimiento y que el proceso persigue una finalidad epistémica. Falta descomponer esa operación en sus fases, porque el diagnóstico de esta tesis depende de distinguirlas. Ferrer Beltrán (2007) propone una descomposición en tres momentos que este trabajo adopta como armazón. La utilidad de la distinción es doble. Permite localizar con precisión en qué fase opera cada restricción jurídica, y permite advertir que la valoración, por sí sola, no decide nada. Esta última consecuencia resulta decisiva para el planteamiento del problema. Entre valorar y resolver media un estándar, y cuando ese estándar no se enuncia el tránsito queda sin control. El apartado reconstruye los tres momentos y muestra a cuál pertenece cada uno de los defectos que documenta el capítulo segundo.

1.3.1. La conformación del conjunto de elementos de juicio concentra las restricciones jurídicas

Ferrer Beltrán (2007) distingue tres momentos fundamentales en la toma de decisiones sobre hechos probados. Son la conformación del conjunto de elementos de juicio sobre cuya base se adoptará la decisión, la valoración de esos elementos y la adopción de la decisión propiamente dicha (p. 41). El autor advierte que se trata de tres momentos lógicamente distintos y sucesivos, aunque en los procesos reales puedan presentarse entrelazados (Ferrer Beltrán, 2007, p. 41). La advertencia importa. Que aparezcan entrelazados en la práctica no autoriza a confundirlos en el análisis, porque cada uno se rige por criterios distintos. Confundirlos produce, como se verá, errores que resultan invisibles mientras la distinción no se traza. El capítulo segundo muestra tres defectos superpuestos que solo se dejan nombrar por separado una vez que los momentos se distinguen.

El primer momento consiste en conformar, mediante la proposición y la práctica de las pruebas, un conjunto de elementos de juicio que apoyen o refuten las distintas hipótesis sobre los hechos del caso (Ferrer Beltrán, 2007, p. 41). Aquí aparece la especificidad jurídica de mayor calado. En los demás ámbitos del conocimiento el conjunto que puede analizarse coincide con el total de las informaciones disponibles y relevantes. En el derecho, en cambio, el conjunto de elementos a valorar es un subconjunto del formado por la totalidad de los elementos

disponibles: aquellos que han sido incorporados al expediente judicial (Ferrer Beltrán, 2007, p. 42). El juzgador no puede resolver con lo que sabe, sino con lo que consta. Esa restricción explica por qué el estudio de los filtros de admisión adquiere relevancia destacada. Lo que queda fuera del expediente queda fuera del razonamiento, por pertinente que sea.

El primer filtro es epistemológico y opera como principio general de inclusión. Una prueba es relevante si aporta apoyo o refutación de alguna de las hipótesis fácticas del caso a la luz de los principios generales de la lógica y de la ciencia (Ferrer Beltrán, 2007, p. 42). A ese filtro inclusivo el derecho añade un número considerable de reglas de exclusión. Ferrer Beltrán (2007) señala que buena parte de ellas se justifican en la protección de valores distintos de la averiguación de la verdad (p. 43). Entre esas reglas figura una que el derecho electoral mexicano aplica con particular rigor. Los propios plazos procesales operan como regla de exclusión, de modo que queda fuera toda información aportada fuera de los plazos previstos, aunque sea relevante (Ferrer Beltrán, 2007, p. 43).

La correspondencia con la ley mexicana es exacta y conviene fijarla desde ahora. El artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece un catálogo tasado de medios admisibles, que funciona como regla de exclusión de los no enumerados. El artículo 16, párrafo 4, dispone que en ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales, salvo la prueba superveniente. Ambos preceptos empobrecen deliberadamente el conjunto de elementos de juicio en nombre de la definitividad de las etapas del proceso electoral. La observación no es una crítica. Es la constatación de que el legislador ya decidió sacrificar riqueza epistémica en el primer momento, lo que vuelve más exigente el tratamiento del material que sí logró entrar.

Ferrer Beltrán (2007) formula una consecuencia que enlaza con el capítulo tercero de este trabajo. Sostiene que el control de racionalidad puede funcionar a posteriori bajo una condición. Debe exigirse al decisor que justifique por qué declaró probados esos hechos y cuál fue el apoyo empírico en el que basó su decisión (p. 44). Los sistemas que carecen de esa exigencia de motivación deben compensarla con reglas de exclusión abundantes, fijadas por anticipado. Los que sí la imponen pueden admitir más material y controlar después. El derecho electoral mexicano pertenece a este segundo grupo, porque los artículos 14 y 16 de la Constitución imponen fundar y motivar. De ahí se sigue que el control por vía de motivación no es

en este ordenamiento un complemento, sino el mecanismo principal de racionalidad.

1.3.2. La valoración es el momento de la racionalidad y su resultado es contextual

Cerrada la composición del conjunto, comienza el segundo momento. Ferrer Beltrán (2007) establece que, bajo un régimen de libre valoración, deberá valorarse el apoyo que cada elemento de juicio aporta a las hipótesis en conflicto, de forma individual y en conjunto (p. 45). La fórmula merece subrayarse porque contiene las dos operaciones que el artículo 16, párrafo 3, de la ley mexicana también exige. El resultado buscado consiste en saber el grado de confirmación del que dispone cada una de esas hipótesis (Ferrer Beltrán, 2007, p. 45). La valoración no produce, por tanto, un veredicto sobre la verdad. Produce una magnitud, que es el grado de apoyo conferido a cada hipótesis en competencia. Esa magnitud admite comparación, y sobre ella opera después el umbral. Confundir la magnitud con la conclusión es el primer paso hacia una decisión incontrolable.

El autor añade dos observaciones que este trabajo utiliza más adelante. La primera es que el resultado de la valoración es siempre contextual, esto es, referido a un determinado conjunto de elementos de juicio (Ferrer Beltrán, 2007, p. 45). Si el conjunto cambia por adición o sustracción de algún elemento, el resultado puede perfectamente ser otro. La consecuencia es de enorme importancia práctica. Omitir del conjunto un elemento que consta en el expediente no constituye un descuido menor, porque altera el resultado de toda la operación. Un tribunal que declara inexistente una prueba obrante en autos no comete un error de detalle. Valora un conjunto distinto del que tenía ante sí, y obtiene por ello un grado de confirmación que no corresponde al caso que resuelve. El vicio no está en la conclusión, sino en el conjunto sobre el que se razonó.

La segunda observación desmonta un equívoco extendido sobre la libre valoración. Ferrer Beltrán (2007) precisa que esa libertad existe solo en el sentido de que la valoración no está sujeta a normas jurídicas que predeterminen su resultado (p. 45). La operación de juzgar el apoyo empírico que un conjunto de elementos aporta a una hipótesis permanece sujeta a los criterios generales de la lógica y de la racionalidad (Ferrer Beltrán, 2007, p. 45). Libertad frente a la prueba tasada no equivale, en consecuencia, a libertad frente a la razón. El autor califica este segundo momento como el momento de la racionalidad. Sostiene que, una vez delimitado el

conjunto, la operación de valorar lo que de él puede inferirse no difiere de la que se realiza en cualquier otro ámbito de la experiencia (Ferrer Beltrán, 2007, p. 46).

De esa caracterización deriva un argumento que conviene retener para el capítulo segundo. Si en el momento de la valoración no rigen reglas jurídicas que predeterminen el resultado, entonces negar la posibilidad de decidir racionalmente en esa fase no puede fundarse en razones específicamente jurídicas. Ferrer Beltrán (2007) lo expresa señalando que tal negativa supone acoger argumentos escépticos generales sobre la posibilidad del conocimiento (p. 46). Las limitaciones propias del contexto jurídico —los plazos, los recursos, la intervención interesada de las partes— hacen que el conjunto disponible resulte epistemológicamente más pobre (Ferrer Beltrán, 2007, p. 46). Empobrecen el material, no la racionalidad de la operación que se practica sobre él. La distinción permite responder a quien alegue que las restricciones del proceso electoral impiden valorar con rigor. Las restricciones acotan el material; no autorizan a tratarlo con menor cuidado.

1.3.3. Sin estándar de prueba la valoración no determina decisión alguna

El tercer momento corresponde a la toma de la decisión, y es donde este trabajo localiza el vacío que pretende llenar. La valoración habrá permitido otorgar a cada hipótesis en conflicto un determinado grado de confirmación que nunca será igual a la certeza absoluta (Ferrer Beltrán, 2007, p. 47). Resta decidir si la hipótesis puede declararse probada con el grado de confirmación de que dispone, y eso depende del estándar de prueba que se utilice (Ferrer Beltrán, 2007, p. 47). La elección de uno u otro estándar es propiamente jurídica y se realiza en atención a los valores en juego en cada tipo de proceso (Ferrer Beltrán, 2007, p. 47). La epistemología suministra el grado y el derecho fija el umbral. Ninguna de las dos disciplinas puede suplir a la otra en esa división de tareas.

El autor enuncia entonces la tesis que sostiene todo el planteamiento del presente trabajo:

Conviene insistir en que el resultado de la valoración de la prueba que se obtenga en el segundo momento no implica por sí solo nada respecto de la decisión a adoptar. Para ello, es necesaria la intermediación de algún estándar de prueba. Y ni siquiera puede darse por descontado que la hipótesis que haya resultado más confirmada es aquella que deberá darse por probada. (Ferrer Beltrán, 2007, p. 48)

La afirmación tiene consecuencias que conviene desplegar. Entre la valoración y la decisión media una operación distinta de ambas. Consiste en

contrastar el grado obtenido con una medida previamente fijada, y sin ella el tránsito de la una a la otra carece de justificación. La valoración informa la decisión, pero no la produce.

Esa operación intermedia no desaparece cuando el ordenamiento omite regularla. Un tribunal que declara probado o no probado un hecho ha aplicado necesariamente algún umbral, porque de otro modo no habría podido pasar del grado a la conclusión. La diferencia entre un sistema con estándar explícito y uno sin él no radica en que el segundo prescinda del umbral. Radica en que lo aplica sin declararlo, y por ello sin exponerlo a discusión. El material puede haber alcanzado un grado alto de confirmación y ser declarado insuficiente, o alcanzar uno bajo y ser declarado bastante, sin que ninguna de las dos decisiones resulte controlable. La arbitrariedad no consiste aquí en decidir mal, sino en decidir sin que nadie pueda verificar contra qué se decidió. La objeción alcanza por igual a las resoluciones que anulan y a las que confirman.

La última observación de Ferrer Beltrán en este punto refuerza el argumento desde un ángulo inesperado. El autor advierte que ni siquiera cabe presumir que la hipótesis más confirmada sea la que deba tenerse por probada (2007, p. 48). El estándar penal de la duda razonable ilustra esa posibilidad. Supone que la hipótesis de la culpabilidad no se tendrá por probada aunque cuente con más apoyo empírico que la de la inocencia, salvo corroboración muy alta (Ferrer Beltrán, 2007, p. 48). El umbral puede, en consecuencia, invertir el resultado de la valoración, y no solo confirmarlo. Un sistema que lo mantiene tácito deja esa inversión fuera de todo escrutinio. Quien no lo enuncia se reserva un poder considerable, porque conserva la facultad de fijarlo después de conocer el grado alcanzado. Esa facultad es justamente la que un estándar explícito suprime.

1.3.4. La distinción de los tres momentos ordena el protocolo y el umbral

La descomposición en tres momentos organiza los dos entregables de esta tesis y conviene dejar explícita la correspondencia. Los dos primeros pasos del protocolo que se propone en el capítulo tercero —el inventario del material indiciario y la acreditación autónoma de cada fuente— pertenecen al primer momento, el de la conformación del conjunto. Los pasos tercero a quinto —la explicitación de la máxima de experiencia, la adminiculación relacional y la contrastación con hipótesis rivales— pertenecen al segundo, el de la valoración. El sexto paso y el estándar escalonado del capítulo cuarto pertenecen al tercero, el de la decisión. La

correspondencia no es decorativa. Cada momento se rige por criterios distintos, de modo que un instrumento diseñado para uno no sirve para otro. Exigir motivación donde falta prueba, o reclamar pruebas donde falta umbral, son errores de diagnóstico antes que de solución.

La distinción permite también precisar el diagnóstico del capítulo segundo. Cuando un tribunal declara que determinados elementos solo constituyen un indicio y que no se aportaron otros, comete errores que pertenecen al primer momento, porque describe mal el conjunto disponible. Cuando omite relacionarlos entre sí, el error pertenece al segundo. Y cuando concluye que el material no basta sin decir cuánto habría bastado, el error pertenece al tercero. Los tres defectos suelen presentarse juntos y confundidos bajo una misma fórmula de rechazo. Separarlos es la condición para nombrarlos, y nombrarlos es la condición para corregirlos. El protocolo del capítulo tercero y el estándar del cuarto operan, por eso, sobre momentos distintos y no son intercambiables entre sí.